

1500699-37.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... de pedreiro e nunca mencionou algo sobre tráfico de entorpecentes, embora tenha desconfiado em certo momento, pois o visualizava fumando maconha. Mesmo assim, nunca descobriu ou procurou saber, pois trabalha o dia inteiro e também à noite, além de nunca ter mexido nos pertences dele. Somente soube que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas na noite dos fatos, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500699-37.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500699-37.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Cleverton Umbelino da Silva

Réu Preso

Vistos.

Cleverton Umbelino da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 01 de junho de 2022, por volta de 22h, na Rua Armando de Moura, altura do nº 164, bairro Parque Três Marias, trazia consigo, e na Rua Juca Esteves nº 660, bairro Centro, ambos os endereços nesta cidade e comarca de Taubaté, tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia (fls. 90/92) que policiais militares, durante operação realizada na quadra de esportes da Rua Armando Moura, visualizaram o réu no centro da quadra. Ao perceber a aproximação da Polícia Militar o réu tentou empreender fuga, mas foi detido. Em busca pessoal foram encontrados consigo onze eppendorfs de cocaína, R\$ 80,00 em dinheiro e um aparelho celular. Durante a abordagem o réu admitiu a posse de drogas também em sua residência, para onde os policiais militares se deslocaram e, após confirmar que se tratava da residência do réu e, ainda, tendo visualizado no local uma embalagem com pequenos tubos plásticos semelhantes àqueles utilizados para a embalagem da droga apreendida em poder do réu, ingressaram no local, onde apreenderam mais vinte e oito porções de cocaína, acondicionadas da mesma forma; onze pequenas porções de crack, droga derivada da cocaína, das quais nove estavam acondicionadas em pequenos embrulhos plásticos e duas envoltas em papel alumínio, além de uma porção maior, ainda indivisa, dessa mesma droga, acondicionada em um embrulho plástico. Apreendida a droga e submetida a exame, comprovou-se que se tratava de cocaína, cuja quantidade e forma de

embalagem evidenciam que era destinada ao tráfico.

Recebida a denúncia, em 24 de junho de 2022 (fls. 93/96), o réu foi citado (fls. 113) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 131).

O processo foi saneado (fls. 135/136). Assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 155/156).

Realizou-se audiência de instrução por teleconferência, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 165/166), oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório e da testemunha da defesa, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo pleiteado a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu e da maior potencialidade lesiva do crack; o reconhecimento da reincidência; não seja aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dada a grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do réu; a fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena e o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos.

A Defesa, em relação às drogas que estavam em poder do réu no início da abordagem, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio. Sustentou que a condição de usuário do réu foi comprovada por seu interrogatório em juízo e na fase policial (fls. 07), em depoimentos referidos na sentença condenatória proferida nos autos nº 0011790-90.2016.8.26.0625 (fls. 172/178), em informações de vida pregressa constantes dos autos nº 0016643-45.2016.8.26.0625 (fls. 171), por antecedentes criminais e quantidade de droga apreendida. Por outro lado, pugnou seja declarada a nulidade do ingresso na residência e das provas ali obtidas, o que já foi reconhecido em audiência de custódia (fls. 70/71) e a instrução probatória apenas reforçou; ademais, (i) a diligência deu-se durante a noite, autorizando a Constituição Federal o ingresso em domicílio durante o dia para cumprimento de mandado; (ii) o réu não autorizou o ingresso policial e não possuía a chave do imóvel, onde não residia de maneira permanente; (iii) os policiais arrombaram a porta sem testemunhas, suas qualificações ou registro de autorização pelo réu, quando poderiam ter solicitado o comparecimento da companheira do réu ou do proprietário do imóvel; (iv) a companheira do réu foi a última a sair do imóvel e nada havia em evidência. Por fim, citou decisão proferida no HC 730.755, pelo STJ, em que reconhecido que a prisão na posse de drogas, por si só, não autoriza o ingresso em residência. Para o caso de condenação, postulou a fixação da pena-base no piso legal; o aumento da pena pela reincidência no patamar de um sexto; o reconhecimento do benefício do art. 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu colaborou voluntariamente e ativamente com a diligência, possibilitando a apreensão do restante dos entorpecentes que se encontravam no imóvel.

É o relatório.

Decido.

O réu está sendo acusado do crime de tráfico de drogas. Sua defesa técnica postulou o reconhecimento de nulidade das provas obtidas após o ingresso na residência onde houve diligência policial, que não teria sido autorizado, a importar em desatendimento ao princípio da inviolabilidade de domicílio. A arguição será apreciada ao longo da fundamentação.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Richardson Alves de Alcantara e David Geraldo Vicente dos Santos narraram que lhes foi solicitado apoio em operação específica de combate ao tráfico de drogas na quadra

esportiva da Rua Armando de Moura. Já no local, após realizado cerco, visualizaram o réu no meio da quadra, o qual tentou se evadir quando percebeu a presença da equipe, sendo detido. Em busca pessoal, localizaram em seu poder onze eppendorfs que continham cocaína, R\$80,00 e um telefone celular Samsung. Indagado, o réu confessou que fazia a venda de drogas no local, sendo o dinheiro em sua posse proveniente dessa mercancia. Disse, ainda, que na casa onde residia havia mais drogas, as quais guardava para um terceiro, cujo nome preferiu não mencionar, de quem receberia a quantia de R\$1.000,00 ao mês. A equipe se deslocou para a Rua Juca Esteves nº 660, onde foi contatado um dos moradores do conjunto de casas tipo kitnet, o qual lhes franqueou a entrada. O réu apontou sua moradia e autorizou que lá adentrassem. Antes, contudo, através da janela puderam visualizar um saco de eppendorfs em cima da geladeira. Conseguiram identificar e contatar via telefone o proprietário das residências, o qual confirmou que o réu e uma moça de prenome Talita residiam no local. Como o réu não possuía a chave, mas já tinha permitido o acesso ao imóvel, entraram forçando a porta principal. No imóvel recolheram o referido saco com eppendorfs e os demais objetos e entorpecentes encontrados no interior da única cômoda que havia no local. Questionado, o réu apontou que Talita era funcionária de um carrinho de lanches no bairro Bosque da Saúde, nesta cidade. Localizaram-na e a cientificaram dos fatos (fls. 02/03 e 05/06).

Em audiência judicial ambos os policiais corroboraram a narrativa da fase policial, reafirmando que o réu confessou que realizava o tráfico de drogas na praça dos fatos. Em acréscimo, disseram que o dinheiro encontrado em poder do réu (R\$80,00) estava em notas diversas, sendo oriundo da venda de drogas. Afirmaram que o réu disse que morava na Rua Juca Esteves com a namorada, há três meses, segundo o PM Richardson, onde haveria mais drogas. Nesse local, um morador abriu o portão de acesso às kitnets, que de acordo com o PM David verbalizou que o réu morava em uma delas. O morador não foi qualificado por não ter envolvimento com os fatos. O proprietário do imóvel também não foi qualificado, pois apenas ligaram para o número constante em uma placa e confirmaram que no local residiam o réu e a namorada, não o envolvendo porque o réu já havia indicado a kitnet, autorizado o ingresso policial no local e, inclusive, que diante da falta da chave, empurrassem a porta, a qual não foi danificada. Ainda do lado de fora, pela janela semiaberta, visualizaram em cima da geladeira vários pinos vazios da mesma embalagem e cor daqueles localizados com o réu. No quarto, na última gaveta da cômoda, havia um tijolo de crack com pouco mais de 1kg, onze pedras de crack, vinte oito pinos de cocaína, frascos de quetaminas, balança de precisão, embalagens plásticas, papel alumínio, R\$155,00 em dinheiro e um celular. Temendo por sua vida, o réu não identificou para quem guardava os entorpecentes. O PM Richardson disse que no local havia objetos pessoais do réu, como vestimentas e tênis. Buscaram a namorada do réu, Talita, em seu trabalho, a qual confirmou que o réu estava morando no local, mas negou conhecimento sobre as drogas. Não conheciam o réu antes dos fatos.

Talita Cristine de Souza Severino, companheira do réu, declarou à autoridade policial que havia conhecido o réu há aproximadamente oito meses, por meio da rede social Facebook, e mantiveram contato, até que começaram a se relacionar, há cinco meses e, poucos dias depois decidiram residir juntos na kitnet onde mora de aluguel, na Rua Juca Esteves, nesta cidade. O réu sempre lhe afirmou que era servente de pedreiro e nunca mencionou algo sobre tráfico de entorpecentes, embora tenha desconfiado em certo momento, pois o visualizava fumando maconha. Mesmo assim, nunca descobriu ou procurou saber, pois trabalha o dia inteiro e também à noite, além de nunca ter mexido nos pertences dele. Somente soube que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas na noite dos fatos, quando policiais militares foram até seu emprego e a informaram sobre a detenção do réu e o motivo (fls. 04).

Já em juízo Talita disse ser companheira do réu e afirmou que moravam juntos na época em que ele foi detido, em uma kitnet que ela alugava há um ano de "Carlão", amigo de seu cunhado, pelo valor de R\$450,00, embora sem contrato de aluguel. Conheceu o réu por meio de amigos em comum, quatro ou cinco meses antes, quando já

morava na kitnet. Iniciaram relacionamento após dois meses. Desconhece onde ele residia anteriormente e conhece apenas de vista a sua genitora. Não o chamou para residir no imóvel, ele apenas “foi ficando” na kitnet, onde ele estava residindo há pouco mais de um mês. Ele às vezes também dormia na casa da genitora. Contudo, na kitnet havia objetos pessoais dele. Trabalhava das 18h às 23h30min e havia saído de casa às 17h, ocasião em que o réu já não estava no local. Nada havia em cima da geladeira quando saiu, tendo trancado a porta, não sendo possível o réu adentrar no imóvel pois ele não possuía a chave. A janela de vidro da kitnet ficava aberta, sendo possível visualizar o seu interior do lado de fora. Policiais a procuraram em seu trabalho, por volta de 21h30min, comunicando-a da prisão do réu e levando-a até a kitnet. Quando chegou, a porta havia sido forçada pelos policiais, os quais lhe mostraram o que havia sido localizado no imóvel, inclusive grande quantidade de droga. Não conhecia os policiais que atuaram na ocorrência, bem como a existência de ilícitos no local. Não sabia do envolvimento do réu com o tráfico de drogas. Nega que ele seja usuário de drogas.

Maria José Umbelina da Silva, mãe do réu, ouvida em juízo narrou que “no mês de junho ele praticamente estava convivendo com a moça”, referindo-se a Talita. Depois disse que “quando o réu foi preso ele revezava entre as casas da mãe e da companheira”. Não conhecia Talita, nem de vista, e nunca a havia visto antes, desconhecendo onde residia. Sabia que o réu estava se relacionando com ela porque ele lhe dizia. Desconhece se o réu é usuário de drogas e nunca o viu alterado em razão disso.

À autoridade policial o réu negou a venda de entorpecentes no local da abordagem. Disse que estava na quadra esportiva apenas fumando um cigarro de maconha quando foi abordado por vários policiais militares. Estes fizeram buscas nas redondezas e acharam, no “meio do mato”, alguns pinos contendo cocaína, dizendo-lhe “a casa caiu”. Consigo havia apenas um telefone celular e a quantia de R\$80,00. Os policiais o levaram para casa, onde mora com Talita, e invadiram o local, pois não autorizou a entrada. Localizaram em sua casa um “tijolo” de crack, pinos vazios, medicamentos veterinários e uma balança, objetos que guardava em sua casa a pedido de “um rapaz” que por medo não identificou. Havia recebido os objetos há dois ou três dias, mediante o pagamento adiantado de R\$1.000,00. Alegou, contudo, que o dinheiro encontrado na residência é proveniente do emprego da sua convivente. Para justificar a quantia em dinheiro que estava consigo e o dinheiro com o qual ajuda Talita, afirmou que havia instalado uma porta de vidro no Colégio Jardim das Nações, nesta cidade, e fez uma parede de tijolos em uma obra em Tremembé, tendo recebido por ambos os serviços (fls. 07/08).

Interrogado em juízo, o réu confessou a propriedade de onze eppendorfs de cocaína, os quais disse que havia acabado de comprar para o próprio uso, o que revelou aos policiais quando foi abordado ao ir embora de bicicleta. Além do entorpecente, portava um celular e a quantia de R\$80,00, proveniente de seu trabalho como ajudante de pedreiro, pelo qual recebe R\$350,00 por semana. Disse aos policiais que residia na Vila Olímpia com a mãe e quem morava na Rua Juca Esteves era uma “menina com quem ficava de vez em quando”. Acredita que os policiais tenham visto o endereço em seu celular, no histórico do aplicativo Uber. Desconhece o motivo deles não terem ido ao imóvel de sua genitora. Já no imóvel de Talita, permaneceu dentro da viatura e não visualizou o que ocorreu, nem o ingresso por meio de morador local, apenas ouviu barulho quando “estouraram” a porta. Somente na audiência de custódia é que teve conhecimento dos objetos localizados no imóvel, desconhecendo se foi apreendido dinheiro além do que estava em seu poder (R\$80,00). Não reside no imóvel de Talita. Negou tenha autorizado a entrada no local, onde havia alguns de seus objetos pessoais (vestimentas) pois lá ficava às vezes. Relacionava-se com Talita há quatro ou cinco meses, considerando a data dos fatos. Não foi quem indicou onde Talita trabalhava e acredita que os policiais tenham visto no seu celular o contato do carrinho de lanches. Enquanto foram buscá-la, permaneceu sentado na calçada acompanhado de policial, não tendo visualizado o que aconteceu

após ela chegar ao local. É usuário não compulsivo de cocaína e maconha, mas ninguém sabia, nem mesmo Talita, fazendo o uso escondido. Tem processos anteriores pelo uso de drogas.

Extraí-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, em ambas as oportunidades em que inquiridos, que o réu foi inicialmente abordado em praça pública, após ter tentado se evadir ao perceber a presença da equipe policial. Em seu poder foram encontrados onze eppendorfs de cocaína, R\$80,00 em notas trocadas e um telefone celular. Aos policiais, durante a diligência, o réu confessou a traficância naquele local, e que o dinheiro então apreendido era proveniente dessa atividade. Disse, ainda, que na casa onde residia havia mais drogas, que estaria guardando para terceira pessoa mediante pagamento mensal. No endereço - fornecido pelo próprio réu e em que situado um conjunto de casas tipo kitnet - um morador abriu o portão de acesso às kitnets. Numa placa estava anotado o telefone do proprietário das casas, que foi contatado e confirmou que o réu e uma moça de prenome Talita residiam no local. O réu indicou sua moradia em específico e, segundo os policiais, autorizou o ingresso no imóvel. O réu não portava a chave da casa e por isso os policiais forçaram a porta principal para ter acesso ao imóvel. No local encontraram um saco de eppendorfs, que estava sobre a geladeira, e na gaveta de uma cômoda havia um tijolo de crack com pouco mais de 1kg, onze pedras de crack, vinte oito pinos de cocaína, frascos de quetaminas, balança de precisão, embalagens plásticas, papel alumínio, R\$155,00 em dinheiro e um celular.

Contrariando sua confissão informal aos policiais durante a diligência, nas duas ocasiões em que formalmente interrogado o réu negou a dedicação ao tráfico de drogas. No entanto, subscreveu confissão sobre seu envolvimento com essa atividade no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar lavrado sobre os fatos (fls. 193/204), especificamente a fls. 195, de que constou sua confirmação sobre estar praticando o tráfico na quadra em que foi abordado, estar na posse de onze pinos de cocaína para a venda a terceiros e de R\$80,00 provenientes da traficância, e residir na casa de sua namorada, onde havia mais drogas, que guardava para terceiro, mediante o pagamento de R\$1.000,00/mês.

Nesse contexto, de nenhum valor probatório suas alegações - contraditórias -, à autoridade policial, de que estava na quadra esportiva apenas fumando um cigarro de maconha e que os pinos de cocaína foram localizados pelos policiais militares no "meio do mato", e em juízo, de que embora portasse os onze eppendorfs de cocaína, havia acabado de comprá-los para o próprio uso, o que teria revelado aos policiais.

Outrossim, ainda se contradizendo, em audiência judicial o réu asseverou ter afirmado aos policiais que residia com sua mãe, negando tê-los informado que residia na casa de sua companheira Talita. Todavia, além de não ter declinado razão para que, ainda assim, os policiais tenham realizado diligência na casa desta última, e não na casa de sua mãe, o réu alegou não ter sido informado sobre o que foi encontrado e apreendido no imóvel, não obstante na fase policial tenha confirmado que residia na casa de Talita e que no local os policiais encontraram um tijolo de crack, pinos vazios, medicamentos veterinários e uma balança, os quais estava mantendo em sua casa mediante o pagamento adiantado de R\$1.000,00.

Ademais, Talita asseverou em juízo que os policiais lhe mostraram o que foi localizado no imóvel, inclusive grande quantidade de droga, e seria incongruente que os policiais não adotassem a mesma postura com o réu.

Não remanescem dúvidas, portanto, de que os materiais apreendidos na casa de Talita pertenciam ao réu, a qual, inclusive, sempre que inquirida afirmou que ele residia no local junto com ela, o que também declarou e assinou no BOPM já referido (especificamente a fls. 197) e se infere também do fato de ambos se qualificarem como companheiros, e não como meros namorados, não sendo contrário a essa conclusão o fato de esporadicamente o réu pernoitar na casa de sua mãe, como por esta

declarado.

Ocorre, todavia, que a despeito da narrativa dos policiais sobre ter o réu autorizado o ingresso no imóvel em que residia e onde encontraram drogas, o réu negou essa autorização peremptoriamente, e houve reconhecimento judicial anterior, em audiência de custódia, sobre a nulidade da diligência e a ilegalidade da prova obtida no interior da residência, sobrevivendo a homologação apenas parcial do flagrante (fls. 70/71), por meio de decisão contra a qual não houve insurgência oportuna.

Some-se a isso o fato de que não foram produzidas provas em contrário sob o crivo do contraditório, posto que em juízo os policiais reproduziram a narrativa da fase inquisitiva, cujo relato sobre a autorização de ingresso no imóvel não foi confirmada pelo réu, o qual manteve sua negativa sobre a autorização, que também não foi comprovada com a juntada aos autos do BOPM (fls. 193/204), do qual não consta declaração do réu, por ele subscrita, sobre autorização de ingresso na residência, embora tenha reconhecido, no mesmo documento, que guardava drogas no imóvel, ainda que para terceiro (fls. 195).

Não se olvide que o réu já estava sob a custódia dos policiais militares e o endereço onde vivia com a companheira era conhecido, porém, ela só foi procurada em seu local de trabalho posteriormente às buscas em seu domicílio, quando isso poderia ter ocorrido antes, para que ela não somente autorizasse, formalmente, o ingresso em sua moradia, mas também abrisse a porta de entrada, de forma a evitar a necessidade de arrombamento, bastando a tanto que se preservasse o local.

Frente ao exposto, deve ser reconhecida a nulidade parcial das provas, ou seja, daquelas obtidas durante busca domiciliar na residência da Rua Juca Esteves nº 660, desconsiderando-se, em consequência, as provas obtidas no imóvel, posteriormente à abordagem policial e busca pessoal, em razão de violação de domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Em consequência, deve ser desconsiderada a apreensão dos seguintes objetos, localizados no interior da residência onde o réu morava com a companheira: um rolo de papel alumínio (quase todo usado); um saco plástico contendo grande quantidade de eppendorfs de cor verde vazios; três pacotes pequenos com grande número de sacos plásticos pequenos marca Talge; vinte ampolas de citrato de fantanila 50mcg/ml; vinte ampolas de epinefrina 1mg/ml, marca Adren; quatro embalagens de quetamina 10ml, marca Vetnil; um telefone celular LG K9; uma balança de precisão, marca Utilidades Planeta; R\$155,00 em dinheiro (parte do comprovante de depósito judicial a fls. 88); onze pequenos embrulhos (nove em papel alumínio e dois em plástico) contendo substância empedrada bege [crack]; um embrulho plástico grande, com formato de tijolo, contendo substância empedrada bege [crack]; vinte e oito eppendorfs de cor verde, contendo substância em pó branca [cocaina], conforme Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/17.

De outra parte, em que pese a nulidade das provas obtidas no imóvel onde o réu residia com a companheira, as quais devem ser desconsideradas, remanescem hígidas as provas obtidas durante a abordagem policial e busca pessoal no réu.

A respeito, como enaltecido, infere-se dos autos que o réu foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na posse direta de onze eppendorfs de cocaina, já embalados individualmente para a venda a terceiros (fotografia a fls. 27). Também portava R\$80,00 em notas trocadas, conforme depoimento dos policiais militares e fotografia a fls. 19, característica comum da prática da venda de entorpecentes.

Informalmente o réu confessou aos policiais a prática da traficância no local onde foi abordado e que o dinheiro em seu poder seria oriundo dessa atividade, o que se

extrai não somente das narrativas dos policiais militares – os quais até então não conheciam o réu e nenhuma razão teriam para pretender prejudicá-lo injustamente –, mas também da declaração assinada pelo réu no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (fls. 195).

Na referida declaração, inclusive, o réu confirmou que no imóvel em que residia com a namorada guardava mais entorpecentes para terceiro, mediante recebimento de quantia em dinheiro, o que também caracteriza o tráfico.

A alegação do réu sobre a destinação ao próprio uso das drogas apreendidas em sua posse direta, como já mencionado, carece de credibilidade dadas as incongruências entre suas declarações.

Ademais, embora o réu tenha asseverado em juízo que é usuário não compulsivo de cocaína e maconha, na mesma ocasião Talita – que na fase policial disse já tê-lo visto usando maconha – negou que ele seja usuário de drogas, e a mãe do réu disse desconhecer essa informação, informando, entretanto, que nunca viu o réu alterado por força do uso de substâncias entorpecentes. Além disso, do conjunto probatório restou evidente que o argumento do réu de que as drogas se destinavam ao seu próprio uso teve o intuito de rechaçar a imputação penal mais severa do tráfico de drogas.

Lado outro, e considerando os documentos apresentados pela defesa (fls. 171/186), salienta-se que o uso de drogas não é circunstância impeditiva de sua concomitante comercialização, atividades que, inclusive, muitas vezes se complementam e financiam-se, o que se evidencia até mesmo pelos antecedentes criminais do réu, não somente por posse de drogas para uso, mas também por tráfico de entorpecentes, a demonstrar que sua conduta não é incipiente.

Há provas suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas. A materialidade também restou comprovada pela lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01) e Boletim de Ocorrência (fls. 09/13), registrando-se a apreensão, em poder do réu por ocasião da abordagem policial, de um telefone celular Samsung de cor azul com capa (fls. 200 do BOPM), R\$80,00 em dinheiro (compondo parte do comprovante de depósito judicial a fls. 88), e onze eppendorfs de cor verde, contendo substância em pó branca (lacre 3411), conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17) e registros fotográficos (fls. 19 e 27).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 21/24), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 167/169), identificou-se que a droga apreendida em poder do réu quando da abordagem, com massa líquida total de 4,08g, tratava-se, efetivamente, de cocaína, pois “foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)”.

Frente ao exposto, é incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu deve ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Passo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Conquanto o réu registre numerosas condenações criminais anteriores (Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 43/49 e Folha de Antecedentes a fls. 50/64), nenhuma delas ultrapassou o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, a fim de ser considerada como mau antecedente e aumentar a pena nessa fase de fixação. Além disso, o réu estava em poder de cocaína, substância entorpecente cujos efeitos deletérios sobre o organismo humano são muito mais drásticos que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil, o

que agrava a potencialidade lesiva de sua conduta, porém, a quantidade de droga apreendida não é relevante e sua divisão em poucas porções não justificam a exacerbação da pena-base.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo as penas-base nos mínimos legais, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Observa-se que o réu possui as seguintes condenações: I. condução de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano (autos nº 0019723-27.2010.8.26.0625, do Juizado Especial Criminal de Taubaté, cujo cumprimento de pena deu-se em 14/02/2021); II. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0005101-06.2011.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, cuja pena estava sendo cumprida em cálculo datado de 16/07/2021); III. posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (autos nº 0008487-78.2010.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, cuja pena está pendente de cumprimento); IV. tráfico de drogas (autos nº 0003538-40.2012.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, com término de cumprimento de pena previsto para 14/09/2017); V. furto qualificado (autos nº 0016643-45.2016.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, cujo cumprimento de pena deu-se em 14/08/2020). As referidas condenações culminam na incidência da agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), específica em uma das hipóteses.

Por outro lado, tem incidência a atenuante da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois ainda que o réu tenha negado a prática do tráfico de drogas em seus interrogatórios formais, durante a abordagem policial confirmou não só a posse das drogas, como também sua destinação à traficância, inclusive que a quantia de dinheiro em sua posse era proveniente dessa conduta, apondo a sua assinatura no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, em que assinalada sua confissão integral quanto aos fatos da abordagem em via pública (STJ, Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio), o que serviu de elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

Deve ser aplicado à hipótese o entendimento do STJ, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, recentemente revisado (junho de 2022), de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585).

Reconhecidas, portanto, ambas as circunstâncias, devem ser compensadas entre si no que atine a uma das reincidências, remanescendo outras que importam no recrudesimento das penas em um terço, a 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Não se identifica a incidência da causa especial de diminuição de penas prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 devido ao réu não ter colaborado com a diligência policial, pois embora tenha indicado que em sua moradia havia mais drogas, tanto na delegacia quanto em juízo negou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, o que contribuiu para a decretação da nulidade das provas obtidas naquele local. Outrossim, ainda que na abordagem o réu tenha afirmado que guardava drogas em sua residência a pedido de terceiro e mediante recebimento de quantia,

recusou-se a identificar o suposto proprietário dos entorpecentes apreendidos no imóvel, deixando de apresentar atitude colaborativa a possibilitar-lhe a aplicação do benefício.

A reincidência do réu impede a aplicação da causa especial de diminuição de penas preconizada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese, não havendo, portanto, causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar, as quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Aplicada pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos e sendo o réu multirreincidente, descabe a substituição por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

Inviável, nesta ocasião, a análise da detração da pena (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º), já que desconhecido deste juízo o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento de eventual direito derivado do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, não se olvidando que o réu registra outras penas pendentes de cumprimento, razões para que se fixe o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Inexistindo nos autos informes sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido na posse direta do réu (R\$80,00), porque não se comprovou tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Cleverton Umbelino da Silva à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 666 dias-multa, com cálculo de seu valor unitário no mínimo legal, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º), não sendo caso de decretar-se a suspensão da correspondente exigibilidade pois não houve pedido expresso a respeito e a hipossuficiência não pode ser presumida.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Está sendo condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual. Além disso, é multirreincidente, havendo inclusive condenações pendentes de cumprimento, o que não o impediu de praticar novo delito, o que demonstra sua ausência de respeito à ordem jurídica.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, oficiando-se.

Ao trânsito em julgado, além das providências de praxe:

i) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$80,00, declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 16/17 e do depósito de fls. 88;

ii) oficie-se à autoridade policial, comunicando-lhe a autorização para incineração do remanescente das drogas apreendidas (v. fls. 104);

iii) providencie-se a restituição ao réu do valor de R\$155,00 apreendido no interior da residência locada por sua companheira, onde as provas produzidas foram consideradas ilícitas. Os demais objetos apreendidos, destinados ao tráfico de drogas, deverão ser destruídos, se inservíveis, inclusive o celular apreendido no interior do imóvel, a menos que comprovada sua propriedade no prazo do art. 123 do Código de Processo Penal.

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 05 de dezembro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA